

刑法
No.348

R1-14 (配点: 2)

月 日

月 日

学生A、B及びCは、次の各【事例】を題材にして、後記【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑧までの()内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【事例】

- I. 店員甲は、自己の担当する売場の商品を勤務時間中にこっそり持ち出して、後日転売した。
- II. 店員甲は、店長乙に言われて、店の売掛金を集金したが、これを持ち逃げした。
- III. 甲は、パーティーで使うために友人乙から借りたネックレスを、無断で質入れした。
- IV. 甲は、登記名義を有する所有者乙から自己使用を条件に借りた土地を、しばらく自己使用した後、無断で丙に賃貸して利益を得た。

【会話】

学生A. 事例Iにおいて、甲にはどのような財産犯が成立するだろうか。

学生B. 店の商品であれば、①(a. 店長・b. 店員)が占有しているといえるから、②(a. 横領罪・b. 窃盗罪)が成立すると思う。

学生C. 反対だ。占有は、③(a. 店長・b. 店員)にあると認めるべきだから、④(a. 横領罪・b. 窃盗罪)が成立すると考える。

学生B. 事例IIにおいて、Cさんの見解によれば、甲に④は成立するののか。

学生C. 成立すると思う。

学生A. その結論は、事例IIにおける判例の立場と一致しない。では、Cさんは、事例IIIにおいても、甲に④が成立すると思うのか。

学生C. いや、成立しないと考える。物を人から借りている場合は別だ。

学生B. そうだとすると、Cさんは、事例IVにおいて、甲には、どのような財産犯が成立すると思うのか。

学生C. 土地のような不動産の場合、動産とは異なり、その占有は、⑤(a. 登記名義を有する者・b. 現実に不動産を占有・使用する者)にあると認めるべきだと思うから、土地に対する占有の程度・態様が著しく変更された場合、甲には⑥(a. 横領罪・b. 不動産侵奪罪)が成立する可能性があると思う。

学生A. そうだろうか。⑦(a. 横領罪にいう「横領」・b. 不動産侵奪罪にいう「侵奪」)があったとはいえないのではないか。むしろ、Cさんの見解によれば、⑧(a. 背任罪・b. 横領罪)の成否を検討すべきだと思う。

1. ①a ②b ③b ④a ⑤a ⑥b ⑦b ⑧a
2. ①a ②b ③b ④a ⑤b ⑥a ⑦a ⑧b
3. ①b ②a ③a ④b ⑤a ⑥b ⑦b ⑧a
4. ①b ②a ③a ④b ⑤a ⑥b ⑦b ⑧b
5. ①b ②a ③a ④b ⑤b ⑥a ⑦a ⑧b

No348	財産犯総合		正答率
R1-14	正解	3	41%

() には、順に「①b ②a ③a ④b ⑤a ⑥b ⑦b ⑧a」が入り、したがって、正解は肢3となる。

①ないし③について

①ないし③は、先に④を確定させなければ答えを導くことができないため、④の後に検討する。

④について

④には、事例Ⅱにおいて学生Cの立場から甲に横領罪(252条1項)と窃盗罪(235条)のいずれが成立するかの帰結が入る。【会話】によれば、その結論は、事例Ⅱにおける判例の立場と一致しないのであるから、判例と異なる犯罪を成立させればよいことになる。大判昭8.9.11は、債権の取立を依頼された受任者が、取り立てた金銭を領得した事案について、横領罪が成立するとする。よって、学生Cの立場からは、甲に窃盗罪が成立する。したがって、④には「b. 窃盗罪」が入る。

③について

③には、事例Ⅰにおいて学生Cの立場から、店の商品の占有が店長と店員のいずれに認められるかの帰結が入る。窃盗罪が成立するには財物に対する他人の占有が必要であるから、商品の占有は他人たる店長に認められる必要がある。したがって、③には「a. 店長」が入る。

①及び②について

①及び②にはそれぞれ、事例Ⅰにおいて学生Bの立場から、店の商品の占有が店長と店員のいずれに認められるかの帰結及び甲に横領罪と窃盗罪のいずれが成立するかの帰結が入る。【会話】によれば、学生Bは学生Cと反対の立場に立っているから、①及び②にはそれぞれ、③及び④と反対の帰結が入る。したがって、①には「b. 店員」が、②には「a. 横領罪」が入る。

⑤について

⑤には、学生Cの立場からの、不動産の占有者の判断基準が入る。最判昭30.12.26は、登記簿上の所有名義人が不動産の占有者であるとするが、学生Cが判例の立場に立っているか否かについては、問題文から判明しない。もっとも、⑤について「b. 現実に不動産を占有・使用する者」を選択した場合、肢2又は肢5のどちらかになるところ、肢2と肢5からは、「⑥a ⑦a ⑧b」が入ることになる。そして、事例Ⅳについて、甲に⑥「a. 横領罪」が成立する可能性があるとの学生Cの発言に対し、学生Aが⑧「b. 横領罪」の成否を検討すべきであるとの反論することは矛盾であるから、かかる肢は誤りである。したがって、⑤には「a. 登記名義を有する者」が入る。

⑥について

⑥には、事例Ⅳにおいて学生Cの立場から、甲に横領罪と不動産侵奪罪(235条の2)のいずれが成立するかの帰結が入る。横領罪の成立には、他人の物に対する「自己の占有」が認められる必要がある(252条1項)。⑤で検討した通り、学生Cは不動産の占有者の判断基準について判例と同じ立場に立っているといえるところ、最判昭34.3.13は、不動産の占有は第三者に対し有効に当該不動産を処分できる状態にある者に認められるとしている。そうすると、事例Ⅳにおいて、土地の占有者は登記名義人たる乙であり、甲は土地を単に賃借しているに過ぎず、当該土地を有効に処分できる状態にあるといえない。よって、甲には「自己の占有」が認められないため、横領罪は成立し得ない。したがって、⑥には「b. 不動産侵奪罪」が入る。

⑦について

⑦には、⑥に対する反論が入るから、『b. 不動産侵奪罪にいう「侵奪」』が入る。

⑧について ★

⑧には、事例Ⅳにおいて学生Cの見解に基づいた場合、甲に背任罪（247条）と横領罪のいずれが成立するかの帰結が入る。⑥で検討した通り、学生Cの見解に基づいた場合、甲には土地の占有が認められず、横領罪は成立し得ない。したがって、⑧には「a. 背任罪」が入る。